

予備独自問題 H24-26

(配点: 3)

月 日

月 日

訴因の予備的記載又は択一的記載に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

1. 本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。
2. 起訴状に3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない。
3. 審理の途中で予備的訴因を追加することも許される。
4. 訴因を予備的又は択一的に記載した場合であっても、「罪となるべき事実」の特定が必要であるから、罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない。
5. 本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合、予備的訴因については無罪判決を言い渡さなければならない。

№151	訴因の予備的記載等	正答率
予備H24-26	正解 1、3 (順不同)	53%

1 正しい

数個の訴因は、予備的にこれを記載することができるが(256条5項)、予備的訴因を記載する場合、当該数個の訴因が公訴事実の同一性が認められる範囲内にしなければならない。そして、「公訴事実の同一性」は単一性と狭義の同一性を含むものであるとされているところ、単一性の有無は、実体法上の罪数判断により解決されると考えられている。併合罪として実体法上数罪と考えられる場合には、公訴事実も数罪であって単一ではないのに対して、数罪が科刑上一罪に関係にあるときは、実体法上一罪であり、単一性が認められるとされる。よって、併合罪の関係にある事実は公訴事実の単一性がなく「公訴事実の同一性」が認められないから、本位的訴因と併合罪の関係にある事実は、予備的訴因とすることはできない。

2 誤っている

256条5項は、「数個」の訴因を予備的又は択一的に記載できるとしているから、例えば予備的記載の場合、検察官は、まず一の訴因(甲訴因)について有罪を求めるとともに、これが否定された場合に備え、第二次的、更には第三次的に他の訴因(乙訴因及び丙訴因)について有罪の判決を求めることが許されることとなる。

3 正しい

312条1項。裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。そして、訴因の追加とは、元の訴因をそのまま残しておいてこれに新しい訴因を付け加えることをいい、起訴時に予備的記載が許される以上(256条5項)、予備的に訴因を追加することも認められるとされている。

4 誤っている

256条5項。数個の訴因又は罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。その趣旨は、1個の公訴事実を数個の訴因に構成し、あるいは数個の罰条を表示することを認めることによって、検察官と裁判所との間で事実上又は法律上の判断を異にすることの結果、本来有罪の被告人が無罪になるという不都合を防ぐ点にある。

5 誤っている

訴因の予備的記載とは、同一の公訴事実の範囲内において犯罪構成要件事実該当する事実が2個以上択一的に存在する可能性のある場合に、第1次のA訴因が認定されないことを停止条件として第2次のB訴因の認定を求める場合をいう。そこで、訴因の予備的記載がなされている場合には、主たる訴因が認定できれば、予備的訴因を審判する必要はないこととなる。

以上により、正しい記述は1と3であり、したがって、正解は肢1と肢3(順不同)となる。